

Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO – In dubio pro disciplinado

Presunta solicitud de dinero que efectuó el funcionario XXXX el día 13 de enero de 2012 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a los viajeros XXX y XXX quienes traían consigo un televisor de 47 pulgadas

El disciplinado fue absuelto toda vez que después de analizar la probatoria obrante al interior de la investigación, se observó por parte de esta Subdirección la presencia de pruebas encontradas que inexorablemente generan dudas insuperables respecto de la ocurrencia del hecho. En tal sentido pudo establecerse que se encontraron elementos suficientes para resolver la actuación a favor del disciplinado en virtud del principio de In dubio pro disciplinado, teniendo en cuenta que, con el material probatorio recolectado, fue imposible superar las dudas sobre la autoría y consecuentes responsabilidad disciplinaria.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 48.1 y 404 del CP

ANTI JURIDICIDAD / EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Por desempeñar funciones ajenas a su cargo sin estar capacitado para atender lo encargado

“...el Despacho considera que la decisión a adoptar, es la absolución, como quiera que existe duda respecto de la autoría y consecuente responsabilidad disciplinaria del señor XXXX. Duda que a la postre es insuperable, habida cuenta que este Despacho ha agotado todas las pruebas posibles, a efectos de establecer la autoría de los hechos... el Despacho estima que al carecer de certeza más allá de toda duda razonable respecto de la responsabilidad del disciplinado, es procedente absolver por el cargo elevado mediante Auto de Cargos No. 17406-010 del 2 de mayo de 2014.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 5 y 9

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-302
Número y fecha del fallo:	17413-08, del 16 de abril de 2015
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-302, el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 17406-010 del 2 de mayo de 2014, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC, formuló pliego de cargos al investigado XXXX. El cargo disciplinario formulado resultó del siguiente tenor:

Cargo

“El señor XXXX, el día 13 de enero de 2012, en horas de la noche, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, abusando de su cargo y de sus funciones de Control Viajeros de la División de la Operación Aduanera de la Seccional de Aduanas de Cali, abordó a los viajeros XXX YYY, provenientes de la ciudad de Miami (EEUU), a quienes solicitó dinero por cuantía que oscilo entre los 60 y 120 dólares de Norte América. Los viajeros cedieron a la solicitud de dinero indebida, ante la amenaza que hizo el disciplinado de decomisar un televisor de 47 pulgadas que habían adquirido en los Estados Unidos por^ valor inferior a mil dólares.

La conducta que se imputa al disciplinado, presuntamente se adecúa a la falta disciplinaria descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por realización objetiva del tipo penal de concusión”

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN ABSOLUTORIA

De conformidad con el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, para proferir decisión sancionatoria se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

Así las cosas, este artículo, analizado a la luz del principio de presunción de inocencia, propio de un sistema de derecho sancionatorio moderno y fundamentado en el Estado Social de Derecho, demanda en el marco del proceso disciplinario, que toda duda debe resolverse en favor del disciplinado.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-302

Es importante recordar en este punto, que el indubio pro disciplinado, figura derivada de la institución de derecho penal liberal de indubio pro reo, es una consecuencia inescindible de la presunción de inocencia, ya que el estado, como regente de la potestad disciplinaria, debe acreditar mediante pruebas legalmente practicadas, la responsabilidad del procesado.

Adicional a lo anterior, la Resolución que declara la responsabilidad disciplinaria debe contar con fundamentos jurídicos y fácticos dotados de plena certeza.

En el sub judice, advierte el Despacho que si bien es cierto existen algunos elementos de juicio que permiten inferir la responsabilidad del señor XXXX, también lo es, que existen otros que hacen presumir la hipótesis según la cual, los viajeros XXXX YYYY, pudieron haber confundido al mencionado funcionario con una tercera persona; quien, a su vez, aprovechando la confusión de las circunstancias hizo una solicitud de dinero a los mencionados ciudadanos.

La falta de claridad de los quejosos a la hora de individualizar al presunto autor de la solicitud de dinero, aunado al hecho, de que quedó probado en el expediente que un funcionario del ICA que responde al nombre XXX, tiene parecido físico con el encartado, y que a su vez también estaba laborando el 13 de enero de 2012; son circunstancias que erosionan la certeza con que debe contar el operador jurídico para estructurar una decisión sancionatoria.

En mérito de lo expuesto, el Despacho trae a colación la disposición normativa de que trata el artículo 9 de la Ley 734 de 2002.

Artículo 9o. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

Respecto a este principio, el Ministerio Público, en calidad de máxima autoridad en materia disciplinaria, Procuraduría Provincial de Girardot, Radicación No. 041-02041/2008, señaló:

"Ahora bien, no existe prueba en el plenario que permita establecer con certeza que el disciplinado, en su condición de Alcalde Municipal de Anapoima, haya conocido y/o intervenido en forma directa en las irregularidades de la ordenación del gasto, en los que presuntamente pueden estar incursos sus mando medios, tal y como se desprende del análisis efectuado a los medios de prueba recaudados en la etapa de instrucción; por lo qué, este Despacho debe dar aplicación al principio procesal IN DUBIO PRO DISCIPLINADO, consistente en que toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado, tal y como lo consagra el artículo 9 de la Ley 734 de 2002-CDU.

Así mismo, el principio in dubio pro disciplinado, emana de la presunción de inocencia, dado que este implica un juicio de valor en lo que hace referencia a los medios de prueba y es obligación dar un tratamiento especial al procesado. En este punto es oportuno traer a colación la sentencia C-097 de 1994 de la Corte Constitucional".

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-302

En otro Pronunciamiento, de la PROCURADURIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA JUDICIAL Y LA POLICÍA JUDICIAL, RADICACIÓN NO. IUC- 011-161140-2007, señaló:

"PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA-Toda duda razonable se resuelve a favor del disciplinado

Uno de los principios que orientan la investigación disciplinaria es la presunción de inocencia, no como resultado de la magnanimidad del Estado ante las diferentes transgresiones de sus servidores sino que es un principio con fundamento constitucional y desarrollado por el legislador como una expresión del Estado Social de Derecho y evitar con él que se den en los diferentes procesos sancionatorios el prejuizamiento o predisposición contra los implicados.

Es con fundamento en este principio que ante la presencia de una duda razonable en desarrollo de la investigación frente a la ocurrencia o no de la falta disciplinaria se deberá resolver a favor del investigado, en aplicación del Artículo 9o. de la ley disciplinaria, en razón a que el "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo", emana de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado, con una duda que debe ser razonable".

Con base en el desarrollo dogmático traído a colación, el Despacho considera que la decisión a adoptar, es la absolución, como quiera que existe duda respecto de la autoría y consecuente responsabilidad disciplinaria del señor XXXX. Duda que a la postre es insuperable, habida cuenta que este Despacho ha agotado todas las pruebas posibles, a efectos de establecer la autoría de los hechos.

Así las cosas, dando aplicación a los principios de presunción de inocencia y de indubio pro disciplinado, el Despacho estima procedente absolver por los cargos elevados al señor XXXX, toda vez que se carece de certeza más allá de toda duda razonable, respecto de la autoría y responsabilidad disciplinaria.

De conformidad con los razonamientos expuestos, el Despacho estima que al carecer de certeza más allá de toda duda razonable respecto de la responsabilidad del disciplinado, es procedente absolver por el cargo elevado mediante Auto de Cargos No. 17406-010 del 2 de mayo de 2014.

OTRAS CONSIDERACIONES

En el marco de la presente investigación disciplinaria, se logró establecer una debilidad en el procedimiento efectuado en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, por parte del Grupo de La División de Operación Aduanera de la Seccional de Aduana de Cali, encargado de la verificación y control de viajeros; consistente en que en el lugar de inspección y verificación de equipajes, se comparte espacio físico con los funcionarios del ICA, cuya labor difiere ostensiblemente de la gestión de autoridad aduanera a cargo de la DIAN.

En tal virtud, como acción preventiva, el Despacho estima pertinente oficiar a la Seccional de Aduanas de Cali, a efectos de recomendarle, haga las adecuaciones que estime pertinentes para evitar el contacto o relación de funcionarios de la División de Operación Aduanera con

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-302

funcionarios de otras entidades en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; así como para evitar se sigan compartiendo de manera directa, los espacios físicos y mecanismos de perfilamiento de inspección física de equipajes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER a XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXX, por la conducta imputada mediante Auto de Cargos No. 17406-010 del 2 de mayo de 2014.

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, a los sujetos procesales, quienes reportaron la siguiente dirección procesal: XXX Avenida XXX en la ciudad de Bogotá XXX en la Calle XXX, Barrio Caldas Urbanización XXX Apartamento A 301 En la ciudad de Cali.

TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente providencia a XXX y **ADVERTIR** que contra la presente decisión procede el **RECURSO DE APELACIÓN**, el cual deberá interponerse en el término de tres días posteriores a la última notificación. Los mencionados podrán ser ubicados en los correos electrónicos XXX y XXX.

CUARTO: DAR CUMPLIMIENTO a través de la Secretaría Técnica de Este Despacho la acción preventiva relacionada en el numeral 7 del aparte considerativo de la presente providencia.

QUINTO: En firme la presente decisión, **COMUNICARLA** en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Dr. Rodrigo Alejandro Rubio Gomez – Secretario Ad-Hoc
Aprobó: Dr. Jorge Adriano Moreno Ponce y Apoderado (a) del (os) investigado (s)